

1500069-63.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Thiago Martins, testemunhas de acusação, foram unânimes ao relatar em juízo que receberam uma denúncia de que o proprietário de um bar, localizado na Rua São Pedro nº 890, bairro São Judas Tadeu, realizava o tráfico de entorpecentes. No balcão do bar, questionaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500069-63.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-63.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2016322/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22519693 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 222/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 223/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2016322 - DEL.POL.SALTO, 222/22/610 - DEL.POL.SALTO, 223/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUZA, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 18 de janeiro de 2022, na Rua São Pedro, nº 890, Jardim São Judas Tadeu, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, a) 89 (oitenta e nove) porções de "cocaína", com peso líquido de 48,91g (quarenta e

oito gramas e noventa e um centigramas) e b) 09 (nove) porções de “maconha”, com peso líquido de 29,44g (vinte e nove gramas e quarenta e quatro centigramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 18 de fevereiro de 2022 (fls. 63-67).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 78-79).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fl. 83-84 ) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade da ação em razão da atuação dos guardas municipais e, no mérito, absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-03, 04-06), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de constatação preliminar (fls. 16) e laudo de exame químico toxicológico (fls.68-71) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Thiago Martins, testemunhas de acusação, foram uníssomos ao relatar em juízo que receberam uma denúncia de que o proprietário de um bar, localizado na Rua São Pedro nº 890, bairro São Judas Tadeu, realizava o tráfico de entorpecentes. No balcão do bar, questionaram o proprietário, Sr. Nilton Cesar, se havia algum entorpecente no local, que respondeu que sim. Apanhou embaixo do balcão um porta garrafas contendo 89 pinos de cocaína. Em revista pessoal foi encontrado em seu bolso direito a quantia de R\$ 1.480,00 e no bolso esquerdo a quantia de R\$ 758,00. No bar foram encontrados, 9 (nove) porções de maconha. No cômodo onde o autor reside, encontraram a quantia de R\$ 611,00, dentro de uma mochila. O acusado confessou que praticava o tráfico de drogas há cerca de dois meses no estabelecimento comercial e o dinheiro era proveniente do tráfico.

O réu Nilton César Rodrigues de Souza, interrogado judicialmente, confessou os fatos, disse que é usuário de maconha e cocaína e também vendeu drogas no bar de sua propriedade.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu guardava e tinha em depósito no estabelecimento comercial a droga todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros.

Não há de se cogitar em nulidade do flagrante em razão da atuação dos guardas municipais que não realizaram qualquer ato investigatório e agiram após provocação de um transeunte, encontrando a droga em estabelecimento comercial, aberto ao público, sem que houvesse violação ao princípio constitucional da inviolabilidade. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por

violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, em conformidade à denúncia anônima, aliadas ao tipo e variedade de drogas e apreensão de considerável quantidade em dinheiro denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150). No caso em apreço, o acusado ostenta condenação extinta há mais de cinco anos, como se observa às fls. 102-103, devendo ser considerada como maus antecedentes.

De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique

a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na hipótese analisada, não obstante os maus antecedentes ostentados pelo réu, observo que a condenação transitada em julgada se deu há mais de 5 (cinco) anos e não se trata de crime da mesma espécie (violência doméstica e familiar contra mulher - autos nº 0003237-65.2009.8.26.0248), não restando demonstrado seu o engajamento no comércio clandestino de drogas, tampouco que integre organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais, sem qualquer investigação prévia. além disso, a quantidade de droga apreendida é pouco expressiva: 48,91g (quarenta e oito gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 29,44g de maconha, justificando a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em grau máximo. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes - Exclusão - Quantidade pouco expressiva - Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação - Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas - Fixação no piso - Inviável maior diminuição por atenuante - Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados - Não incidência. Redutor - Cabimento - Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes - Redutor máximo - Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Por fim, cabe ressaltar que partir do julgamento do HC 97.256 pelo STF, quando foi declarada incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do artigo 44 da Lei de Drogas, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é portador de maus antecedentes (fls. 102-103), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, fixo a pena em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 468 dias-multa .

Na terceira fase, reconheço o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 156 dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 156 dias-multa, no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado. Expeça-se alvará de soltura.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Oportunamente, ao arquivo. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA